

제48회 특허법 기출문제 해설 (김남혁 변리사)

1. 설문(1)에 대하여 - 등록가능성 <B-1>

1. [문제의 소개] 乙이 당해출원의 정당한 권리자인지, 신규성 상실사유가 있는지 살피고, 신규성과 관련하여 제30조의 적용여부가 문제되는데, 출원시 취지기재 하지 않았던 것을 추후 보정으로 극복가능한지 判例의 태도를 중심으로 검토하고, 등록받을 수 있는 방안을 살펴보겠다.
2. [정당한 권리자 인지] 乙은 제조방법 K의 발명자는 아니나, 발명자 丁으로부터 특허 받을 수 있는 권리를 적법하게 양수한 정당한 승계인으로서 제33조 1항 본문 위반은 없다.
3. [신규성 상실사유] i) 제29조 1항 각호의 발명과 동일성 있는 발명은 특허 받을 수 없다. 특허권은 신규한 기술을 공개한 대가로 주어지는 것이기 때문이다. ii) 甲의 특허권의 명세서에 제조방법 K가 기재되어 있다면 반포된 간행물에 게재 된것으로서 신규성상실사유 존재하지만 설문의 사정만으로 이를 주단할 수 없다. iii) 丁은 09.5.2 제조방법 K에 관한 논문을 발표 하였는바 비밀유지의무가 없는 불특정 다수인에게 공시된 것으로서 신규성 상실사유에 해당한다.
4. [공지예외주장] i) 출원전 이미 공지된 것이라도 일정요건 만족하여 출원한 경우 출원인의 이익위에 신규성 판단시 공지 되지 않은 것으로 본다. (제30조) ii) 의사에 의한 공지의 경우 (제1항 1호) 공지된 날부터 6월 이내에 출원시 취지를 기재하여 출원하여야 하고, 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출해야 한다. iii) 공개자(丁)와 출원인(乙)이 동일인이 아니지만 추후 증명서류를 통해 공지 후 적법한 승계임을 주장하면 되므로 이는 문제 되지 않는다.
5. [취지기재의 보완가부] i) 특허법원은 제30조 1항 규정의 취지 및 의사에 반한 공지와의 영평상 출원후 취지 기재의 보정을 허용하였으나 ii) 대법원은 제30조 1항에서 정하는 공지예외주장은 출원과 별개 절차이므로 출원서에 취지기재가 없으면 그 주장이 없는 통상의 출원에 해당하는바 출원 후 그에 관한 보정은 허용 될 수 없다고 한다. iii) 법적안정성의 견지에서 대법원 판례가 타당하다고 판단되므로 이에 따른 검토를 하겠다.
6. [설문(1)의 해결] 乙은 공지(09.5.2)로부터 6월이내 출원하였으나, 출원시 취지기재를 하지 아니한바 그 후 공지예외 적용대상 취지를 기재한 서면을 제출하였더라도 이는 제30조 2항의 증명서류로서의 의미만을 가질 뿐 출원시 취지기재 하지 않은 것에 대한 보정으로 볼 수 없을 것이다. 따라서 제30조 1항 1호의 공지예외주장의 효력을 적용받지 못한 乙의 당해출원은 신규성 위반으로 등록받을 수 없을 것이다. 다만, 당해 출원을 취하후 최초공지(09.5.2)로부터 6월이내인 09.11.2 까지 재출원하면서 제30조 주장을 적법하게 하였다면 등록받을 수 있을 것이다.

II. 설문(2)에 대하여 - 심판청구가 적법한 것인지 여부 및 甲의 주장의 인용여부

1. [문제의 소재] i) 심판청구의 적법성에 관하여 간접침해 물품에 대하여 권리범위확인심판이 가능한지를 중심으로 살피고, ii) 甲주장의 인용여부와 관련하여 a+b가 권리범위에 속하는지 구성요소 완비의 원칙에 따른 판단 및 전용품에 해당하는지를 판단하여 보겠다.

2. [권리범위확인심판] i) 권리범위확인심판이란 특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인의 청구에 의해 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하는지 확인하는 심판(제135조)이다. ii) 判例는 권리범위확인심판은 당사자간의 사실관계의 확정인 아닌 권리범위의 효력을 확인하는 법률관계의 확정을 목적으로 한다고 한다. ii) 설문에서는 특허권자 甲이 乙을 상대로 제기한 적극적 권리범위확인심판으로서 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단되면 인용심결을 하고, 속하지 않는다고 판단되면 기각심결을 알뿐, 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 내릴 수는 없다.

3. 심판청구의 적법성

(1) [서론] i) 적법성 심리란 심판청구 자체의 적법성 여부를 심리하는 것으로서 심리결과 부적법한 경우 심판관 합의체는 심결로써 이를 각하한다, (제142조) ii) 특허권자 甲이 특허권 존속 중에 a+b를 실시하고 있는 乙을 상대로 심판청구안바 청구인적격 및 확인의이익을 만족한다.

(2) [간접침해를 이유로 한 권리범위확인심판 청구의 가부] i) 권리범위확인심판을 청구하기 위해서는 확인대상발명이 당해 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 특정되어야 하는데 간접침해 물건은 특허발명의 구성요소를 모두 구비하고 있지 않은바 이 같은 영식논리를 그대로 관철한다면 당해 심판을 구할 수 없다는 문제가 있다. ii) 간접침해 행위도 특허권에 대한 침해행위로 규정되어 있으므로 심판청구를 가능하도록 해야 할 필요성이 있다. iii) 다만, 간접침해는 법률적으로 규정된 특정행위(제127조)가 특허권을 침해한 것이라고 하는 것이지 그 물건이 당연히 권리범위에 속한다고 하여 권리범위를 확장한 것은 아니므로 상대방행위와 무관하게 확인대상발명 자체가 권리범위에 속한다고 선언 할 수 없다는 견해가 있으나 iv) 判例는 특허가 방법의 발명인 경우에 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 확인을 구할 수 있다고 판시하여 간접침해 물건을 확인대상발명으로 하여 권리범위확인심판을 구할 수 있음을 명확히 하였다.

(3) [소결] i) 간접침해의 경우 기술적 대비대상(실시발명)과 권리범위 속부 확인의 대상(간접침해 대상물)이 분리되지만 이것이 권리범위확인심판의 본질에 반한다고 볼 수 없는바 判例의 태도가 타당하다. ii) 따라서 甲이 설명서 및 필요한 도면을 첨부 (제140조 3항) 하여 반제품 a+b를 적법하게 특정하였다면, 당해 심판청구는 적법할 것이므로 본안심리를 하여야 할 것이다.

4. 甲의 주장의 인용여부

(1) [서론] i) 제97조 및 제42조6항을 근거로 청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하여야만 보호범위에 속한다는 구성요소완비의 원칙에 의할 때 ii) 설문에서 乙의 a+b의 실시에는 특허발명의 구성요소 c가 제외되어 있는바 이가 간접침해에 따른 판단을 하겠다.

(2) [간접침해의 의의] i) 직접침해는 아니지만, 특허발명의 생산에만 사용되는 물건에 대해서는 침해의 개연성이 높아 특허권자의 실질적 보호위에 침해로 간주한다. (제127조) ii) 물건발명에

대안 간접침해에 있어서는 특허발명 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도 등을 업으로써 하는 것을 말한다.

(3) [간접침해의 요건] i) “공용성” - 간접침해 대상물이 특허발명의 생산에 사용되는 관계에 있어야 한다. 判例는 ‘생산’에 대하여 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만드는 모든 행위를 의미한다고 한다. ii) “전용성” - 타용도가 없다는 것을 의미하며, 타용도에 관해 判例는 경제적, 상업적, 실용적 사용사실 또는 확실한 사용가능성을 의미하고, 막연한 사용가능성 만으로는 부족하다고 한다. v) “간접침해 대상물을 업으로써 생산·양도등을 할것” - 물건의 사용행위가 제외되는 점 외에는 물건에 관한 일반적인 실시 태양과 동일하다. (제2조 3호 가목) vi) 간접침해가 성립하려면 직접침해 있어야 한다. 는 종속설이 있으나 제127조의 요건을 만족하면 성립된다는 독립설이 명문규정과 특허권자의 이익 보호상 타당하다.

(4) [소결] 설문에서 일부구성요소가 결여된 확인대상발명 a+b는 모든 구성요소를 가진 특허발명 a+b+c의 생산에만 사용되는 물건으로서 심결시 기준으로 공용성 및 전용성을 만족하며 乙은 이러한 반제품 a+b를 ‘생산’ 및 ‘丙에게 공급(양도)’ 한바, 요건을 모두 만족하므로 특별한 사정 없는 한 권리범위에 속한다는 인용심결을 할 것이다.

I. 문제의 소개 <B-2>

i) 동일한 심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 공동으로 심판의 청구를 할 수 있는데 (제139조 1항) 공동심판청구인 간에 무요심결이 분리확정 되는지와 관련하여 소송의 성격이 문제된다. ii) 심결취소소송은 특허심판원이라는 행정기관의 처분에 대한 적법성여부를 판단하는바 행정소송에 해당하며 심판의 결정·심결을 불복하는 항고소송의 성질을 가진다.

II. 설문(1)에 대하여 - 공동심판의 심결취소소송의 성격

1. [고유필수적 공동소송] i) 고유필수적 공동소송이란 공동소송이 강제되고 압일확정이 필수적으로 요구되는 소송인데 실제법상 관리처분권이 공동귀속되는 경우 해당된다. ii) 甲과乙은 실제법상 관리처분권을 공동귀속한다고 할수 없는바 고유필수적 공동소송이 아님은 명백하다.

2. [견해의 대립] i) 처분권주의와 변론주의를 근거로 통상공동소송에 불과하다는 통상공동소송설 ii) 심결의 대세요를 근거로 압일확정 요청상 유사필수적 공동소송이라는 유사필수적 공동소송설 iii) 일사부재리가 적용되는 경우에 한해 유사필수적 공동소송이라는 견해가 있다.

3. [判例의 태도] i) 특허법원 판례 중에는 유사필수적 공동소송설의 입장을 취한 것과 통상공동소송설의 입장을 취한 것들이 혼재되어 있으나, ii) 최근 대법원은 공동심판청구인 중 1인만을 상대로 심결취소소송을 제기 하였다 하더라도 모두 확정기 차단된다고 하여 유사필수적 공동소송설이 입장이다.

4. [검토] 무요심판은 공동으로 청구하는 것이 강제되지 않아 심판절차가 병합되지 않는 이상 별도의 심결이 내려져 각각 확정될 것인데, 공동으로 심판청구 된 우연한 사정으로 인해 결과가 달라진다는 문제점이 있긴 하지만, 특허권의 대세요 및 심결의 모순·저촉방지 위한 압일확정의 요청상 유사필수적 공동소송이라고 보는 대법원의 判例가 타당하다.

III. 설문(2)에 대하여	
1. [당사자 적격] i) 당사자적격이란 특정의 소송사건에 있어서 정당한 당사자로서 소송을 수행하고 본안판결을 받기에 적합한 자격을 말하는데 무의미한 소송을 배제하기 위함이다. ii) 직권조사사양으로서 소송요건이며 음결시 소각아 된다.	
2. [원고적격 판단] i) 심결취소소송에서 원고적격자는 당사자, 참가인, 참가신청을 하였으나 거부된 자인바, (제186조2항) 특허권자 A는 심결의 당사자이므로 원고적격 만족한다. ii) 다만, 통상공동소송으로 판단한 특허법원 판례에 따르면 제소기간 내에 乙에게 소가 제기 되지 않으면 분리확정 되는바 특허권이 무효로 확정되어 A로서는 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없게되어 소각아 판결될 것이다.	5
3. [피고적격 판단] i) 당사자에게 심판에서의 피고적격자는 심판의 청구인 또는 피청구인이다. (제187조) ii) 고유필수적공동소송으로 볼 경우 甲과乙의 공동소송이 강제되지만 iv) 判例는 유사필수적공동소송으로 보는바 甲만을 상대로 제기한 경우라도 피고적격을 만족한다.	10
4. [당사자 추가] i) 특허법원 판례 중에 당해 소송의 성격에 대하여 유사필수적 공동소송으로 보는 것과 통상공동소송으로 보는 것이 온재 되어 있으나 모두 당해 소송의 경우 공동소송이 강제되는 고유필수적 공동소송이 아니므로 당사자 추가신청 (민사소송법 제68조) 은 부적법하다고 판시 하였으며, ii) 대법원 판례 역시 당사자 추가를 허용하지 않고 있다.	15
IV. 설문(3)에 대하여	
1. [문제점] 甲과乙의 공동심판청구를 기각하는 심결 후 甲만이 A를 상대로 심결취소소송을 제기했을 때 당사자 적격에 관하여 문제되며 누락된 乙의 구제방법에 대해 검토한다.	
2. [유력한 견해] 제139조 1항에 의한 공동심판은 유사필수적 공동심판의 성격을 가지며, 심결 후 청구인 전원에 대하여 출소기간이 경과하여야 심결이 확정되므로 1인이라도 소송을 제기하면 심결은 확정되지 않고, 출소기간을 경과한 청구인은 스스로 심결취소소송을 제기 할 수는 없지만 심결이 확정되지 않았으므로 심결을 취소하는 판결이 확정됨에 의해 다시 심판이 계속되면 그 심판에서 심결취소소송을 제기 하지 않은 청구인도 심판청구인으로서의 지위를 유지하게 된다는 유력한 견해가 있다.	20
3. [判例] i) 대법원 판례는 특허 무효심결이 확정 된 때에는 당해 특허는 제3자와의 관계에서도 무효가 되므로 2인이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 청구인들 사이에 합의확정을 필요로 안하는 유사필수적 공동심판에 해당한다고 하여 위 견해를 지지하였으며. ii) 일본 최고재판소 판결 역시 공동심판청구인 중 1인의 소제기도 적법하다고 했다.	25
4. [당사자 적격 판단] i) 상기 살펴본 바와 같이 당해 심판은 유사필수적 공동심판에 해당하여 공동소송이 강제되지 않는바 甲은 공동심판의 당사자로서 원고 적격을 가지며 (제186조 2항) ii) 특허권자 A는 공동심판의 피청구인으로서 피고 적격을 가진다. (제187조)	30
5. [당사자 추가] i) 乙의 제소기간이 지나지 않은 경우라면, 신소를 제기하여 특허법원의 변론병합을 통해 공동소송을 하거나 공동소송참가 (민사소송법 제83조) 를 할 수 있을 것이고 ii) 제소기간이 경과한 경우라면 보조참가를 할 수 있을 뿐이다.	